

1500177-61.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500177-61.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500177-61.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030267/2022 - 02º D.P. AMERICANA, 22781016 - 02º D.P. AMERICANA, 197/22/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2030267 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILQUER DOS SANTOS BASTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

WILKER DOS SANTOS BASTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", e §1º, inc. I, da Lei nº. 11.343/2006 e nos art. 180, "caput", e art. 311, "caput", ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo e transportava, bem como tinha em depósito, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (05 tijolos e 03 porções de maconha, revelando peso líquido de 3.203g - no total), que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e, ainda, 01 (uma) porção de lidocaína, com peso líquido de 72g (setenta e duas gramas), insumo destinado à preparação e adulteração de drogas que

consta na Lista III da Portaria MJ 240/2019 (fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer concentração). Consta, ainda, que adquiriu ou recebeu, em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime e, também, adulterou sinal identificador de veículo automotor.

Consta, ainda, da exordial que:

Policiais militares em patrulhamento de rotina visualizaram o veículo automotor CHEVROLET/Onix, placas FQS-6B29, conduzido pelo denunciado e lhe deram sinal de parada, todavia WILKER não atendeu a determinação e empreendeu fuga, sendo acompanhado pela viatura e abordado na Rua Francisco Garbo, altura do número 1.563. Submetido à revista pessoal, consigo nada foi encontrado; durante busca no aludido automóvel, os policiais localizaram cinco tijolos de maconha, embaixo do bando traseiro (fls. 48), além de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em notas diversas.

Diante desse quadro, solicitaram a documentação pessoal e do automóvel, tendo o denunciado informado que estavam em sua residência, situada na Rua Jair Amorim nº 431.

Uma vez no imóvel, franqueada a entrada pela esposa do denunciado, que prontamente afirmou haver drogas na casa, e que a ele pertenciam, inclusive indicando o local, os policiais encontraram, no interior de um armário existente na lavanderia, uma embalagem contendo três porções de maconha, e um saco plástico contendo uma porção de lidocaína, além de três cadernos e duas folhas de anotações aparentando contabilidade, vários comprovantes de depósito, uma balança de precisão, um rolo de plástico-filme e diversos saquinhos plásticos comumente usados para embalar drogas (fls. 50/51).

Verificando a situação do veículo automotor que ele dirigia, os policiais observaram que o emplacamento não correspondia ao número do chassi e, após pesquisa, descobriram que se tratava de produto de roubo ocorrido em 31 de janeiro de 2.022 na cidade de Hortolândia/SP (boletim de ocorrência juntado às fls. 52/53), cujo emplacamento é FBH-5770.

Indagado a respeito, WILKER informou ter adquirido aludido automóvel no submundo do crime e nele colocou as placas FQS-6B29, que na verdade pertencem ao seu automóvel CHEVROLET/Onix, recentemente capotado, adulterando, com isso, o sinal identificador de veículo automotor.

O denunciado, à evidência, sabia da origem criminosa do automóvel em questão uma vez que não possuía a documentação pertinente, e sequer forneceu dados identificadores de quem lhe passou o bem. Outro dado que demonstra a má fé do agente é o fato do automóvel que conduzia estar com emplacamento diferente, que ele mesmo providenciou a adulteração.

Retornando à questão das drogas, correto afirmar que a grande quantidade de drogas e insumo apreendidos, a forma como estavam acondicionadas, a apreensão de dinheiro, certamente obtido no comércio deletério, bem como a apreensão de balança de precisão, cadernos e folhas com anotações, plástico-filme e diversos saquinhos plásticos, somadas às demais circunstâncias da prisão em flagrante, compreendendo os depoimentos obtidos em sede policial, demonstram claramente que as substâncias apreendidas se destinavam a consumo de terceiros, a qualquer título.

A denúncia de fls. 113/115, foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 117/120).

O réu foi citado (fls. 238), apresentando defesa (fls. 250/261 e 265/268). Houve manifestação do Ministério Público (fls. 281 e 286), e manutenção do recebimento da denúncia (fls. 282/285 e 290/291).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 328/329).

Em seus memoriais (fls. 404/408), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que

estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 426/445), requereu a absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena mínima com regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes, receptação e adulteração se encontra comprovada pelos autos de fls. 01 (prisão em flagrante), 08/11 (Boletim de Ocorrência), 12/14 (auto de exibição - drogas e apetrechos) 15/16 (auto de apreensão e entrega do veículo subtraído), 44/51 (fotografias) e 52/53 (B.O. do roubo) e laudos de fls. 54/52 (constatação de drogas), 124/126 (toxicológico definitivo), 390/398 (apetrechos) e 399/400 (impressões).

Não há dúvida que a droga "cannabis sativa", popularmente conhecida por "maconha" causa grave dano à incolumidade pública.

Nesse sentido, o editorial do jornal Folha de São Paulo do dia 21 de fevereiro de 2000:

MACONHA E DEPENDÊNCIA

Observa-se, em São Paulo, um aumento no número de casos de pessoas que procuram ajuda médica devido a complicações relacionadas à maconha. Trata-se de uma tendência ainda não quantificada em termos científicos, mas algumas clínicas registraram um acréscimo de 20% na demanda por esse atendimento. A Universidade Federal de São Paulo inaugurou, há três semanas, um ambulatório para esses pacientes. A maconha ainda está longe de constituir um problema de saúde pública, pelo menos um problema tão grande como os 10% de dependentes de álcool na população ou os inúmeros viciados em cocaína e crack. Isso, obviamente, não é razão para fechar os olhos para a questão.

Esse fenômeno com a maconha se explica, em parte, devido a uma mudança de paradigma na psiquiatria. Até meados dos anos 80, a dependência em relação a uma droga era avaliada basicamente pela tolerância (a necessidade de usar cada vez mais para obter o mesmo efeito) e pelo nível dos sintomas de abstinência (os efeitos físicos desagradáveis provocados pela retirada da droga). Em 87, a Associação Americana de Psiquiatria decidiu incluir também critérios psicossociais que indicassem um envolvimento sério do indivíduo com a substância para determinar se ele era ou não um dependente. Trocando em miúdos, pode ser considerado dependente todo aquele cujo envolvimento com alguma droga lhe provoca problemas sociais. Essa nova visão faz mais sentido. Afinal, o ser humano carrega em sua herança genética ou cultural uma fabulosa capacidade de ligar-se de forma patológica a determinados comportamentos, com ou sem drogas. É o caso, por exemplo, dos jogadores compulsivos. Aí, o próprio cérebro pode estar produzindo substâncias que o levam ao vício. São os chamados opióides endógenos. A literatura médica também registra episódios de dependências mais exóticas, como a de comer cenouras. Não se sabe ao certo se o beta-caroteno encontrado nesse vegetal tem potencial aditivo ou se o vício teria explicação em ritualizações. De todo modo, para a imensa maioria das pessoas, a cenoura é apenas um alimento, e saudável. Tudo está na forma como o indivíduo se relaciona com a droga, que pode ser patológica ou não, dependendo de inúmeras variáveis relacionadas à própria substância e à personalidade do usuário. O fato é que não faz mais tanto sentido falar em drogas leves. Droga é droga e muitas vezes tem consequências desastrosas. (os grifos são meus).

No mais, os laudos periciais comprovaram a existência de insumos químicos

utilizados na fabricação e síntese de entorpecentes ou psicotrópicos, além de substâncias psicotrópicas de uso proscrito e que determinam dependência física e psíquica.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUBSTÂNCIA DESTINADA À PREPARAÇÃO DE "LANÇA-PERFUME". SÚMULA 83/STJ. 1. (...). 3. Verifica-se a conformidade entre o posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de reconhecer como típica a conduta de possuir matérias-primas e insumos usualmente associados à produção de substância entorpecente, como no caso destes autos, em que o agravante foi flagrado na posse de, aproximadamente, 10 litros de clorofórmio, substância empregada na produção de cloreto de etila, também conhecido como "lança-perfume". (...). (AgRg no AREsp 1068525/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, o Policial Militar Lucas informou que estavam em patrulhamento na região com vistas a veículos furtados e roubados. Narraram que visualizaram um veículo Ônix preto, com insulfilme, o qual ao avistar a viatura adentrou uma rua em alta velocidade, motivando a ação policial. Disse, ainda, que, dando ordem de parada seguiram o automóvel, o qual tentou evadir-se por algumas ruas, quando foi possível efetuar a abordagem e, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, sendo que o motorista/réu encontrava-se nervoso. Em revista no veículo, embaixo do banco traseiro foram encontrados cinco tijolos aparentando ser maconha, e uma quantia em dinheiro. Indagado, o réu confirmou que fazia o abastecimento da droga, e indicou participar do PCC. Como o réu morava próximo, deslocaram-se ao local, onde a esposa do réu permitiu a entrada e indicou a existência de mais substâncias entorpecentes, sendo que foram localizadas mais

drogas, anotações, depósitos, embalagens e apetrechos, na lavanderia. Ainda, ao consultar a placa do veículo e seu chassi, foram verificadas divergências, sendo constatado que o automóvel era produto de roubo em Hortolândia. Indagado, o réu alegou que havia capotado seu veículo Ônix e que teria comprado esse roubado para arrumar seu carro. Por fim, atua na região de Piracicaba e desconhecia o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Rodrigo, o qual reforçou que estavam em patrulhamento na região, visando o roubo/furto de veículo, sendo que o modelo Ônix era um dos mais subtraídos. Em determinado momento, um veículo Ônix preto, ao visualizar a viatura, virou uma rua em certa velocidade, chamando a atenção dos policiais. Deram ordem de parada, a qual não foi inicialmente obedecida. Efetuada a abordagem, em revista no veículo localizaram no banco traseiro a substância entorpecente e uma quantia em dinheiro. Indagado, o réu afirmou que a documentação pessoal e do veículo estavam na residência, sendo solicitado apoio de outra viatura e dirigiram-se ao local. Na residência, foram recebidas pela esposa do réu, a qual indicou a existência de mais drogas pertencentes ao réu, e autorizou a entrada, sendo localizadas na lavanderia mais drogas, além de insumos e apetrechos, sacolas e anotações. Relativo ao veículo, ao consultar a placa e o chassi foi verificado que divergiam, e que o automóvel era produto de roubo. Indagado, o réu alegou que capotou seu veículo e que havia pego o outro automóvel pelas peças, e que apenas havia feito a troca das placas para poder andar pela cidade, até o conserto do seu carro. O réu ainda confirmou que fazia parte do PCC, e que a droga estava transportando para outro local. Por fim reconheceu o réu em Juízo.

Ainda, a testemunha Alessandra, ouvida em Juízo, disse que seu veículo foi roubado em Hortolândia, por duas pessoas. O veículo foi recuperado, com trocas das rodas e ausência de itens de segurança e placas. Por fim, não reconhece o réu como um dos autores do delito.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eundem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas (“Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos

depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida - Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP - pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Impetração visando a absolvição do apelante por fragilidade probatória, com base na negativa de autoria e nas contradições existentes nas versões dos policiais - IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade comprovadas - Negativa de autoria isolada nos autos - Depoimentos dos policiais com pequena contradição referente ao papel do apelante no tráfico que não afeta a decisão condenatória - Testemunhas de defesa que apresentaram declarações com detalhes sequer mencionados pelo apelante, em seu interrogatório - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Criminal 0004594-74.2014.8.26.0161; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 29/08/2016)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Inclusive, julgando Apelação Criminal oriunda deste juízo, assim decidiu a 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ressalte-se que, eventuais discrepâncias entre os depoimentos não geram insegurança acerca dos fatos, pois oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada, sendo, sim, importante, verificar se, embora divergentes em detalhes mínimos, concordam os testemunhos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias mais decisivas dos fatos" (Apelação Criminal nº 00976517.3/3-0000-000, Rel. DES. FERNANDO MATALLO, 24.05.2007).

Em que pesem as alegações da defesa acerca da abordagem imotivada ou da entrada ilegal, a preliminar suscitada deve ser afastada. Preliminarmente, verifica-se que os policiais informaram que se encontravam em patrulhamento direcionado a ocorrências de furto e roubo do modelo do veículo apreendido, sendo que o réu, inicialmente, recusou a ordem de parada, motivando a abordagem.

Com efeito, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do policial militar ou guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de

Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. Além disso, o direito à inviolabilidade do domicílio possui exceção na própria constituição, no caso de flagrante delito.

Tendo em vista que o delito de tráfico de entorpecentes é delito permanente, cuja consumação se protraí no tempo, não há nenhuma ilegalidade na atitude dos policiais.

À respeito da natureza permanente do delito, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "Dispõe o artigo 303 que, nas infrações, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, o que, na verdade, é despiciendo, já que, nessa espécie de ilícito, a consumação se prolonga no tempo, dependendo da vontade do agente, como ocorre nos crimes de seqüestro (art. 148, do CP), de extorsão mediante seqüestro (art. 149, do CP), nos crimes cuja conduta é 'guardar consigo \ 'ter em depósito', 'transportar' etc. Nessas hipóteses o crime está sendo cometido durante o tempo da consumação, havendo, pois, caso típico de flagrância. O dispositivo, porém, evita qualquer interpretação em contrário, cumprindo ressaltar que é ele repetido no Código de Processo Penal italiano de 1988 (art. 328,2). Não se contesta a situação de flagrância nessas hipóteses, inclusive quanto ao crime de quadrilha, em ação de transporte de coisas subtraídas, de receptação dolosa por ocultação, de depósito de substância entorpecente etc. Evidentemente, tratando-se de prisão em flagrante, mesmo nas hipóteses em que se deva invadir casa alheia, não se exige mandado judicial (g.n. -Processo Penal - 3a ed. - Ed. Atlas - 1994 - pág. 360).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO. Direito de recorrer em liberdade. Perda superveniente do objeto. Prova ilícita. Inexistência. Situação flagrancial que autoriza o ingresso na residência independentemente de ordem judicial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Tráfico ilícito de entorpecentes. Insuficiência de provas. Inocorrência. Circunstâncias que evidenciam que a droga se destinava à mercancia. Palavra dos agentes policiais que merece crédito. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Pena privativa de liberdade. Majoração da pena-base de rigor. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Pena intermediária. Atenuante genérica da confissão. Cabimento. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Regime inicial de cumprimento da pena. Regime fechado que se mostra mais adequado ante as circunstâncias do caso concreto, a despeito do teor do art. 387, §2º, do CPP. Pena restritiva de direitos. Não cabimento. Manutenção da prisão. Persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva agregada à possibilidade de execução provisória da pena após a prolação do acórdão condenatório. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000004-65.2015.8.26.0631; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Amparo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 29/11/2016)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, após chegada ao local para

averiguação de "denúncia anônima" recebida acerca da chegada de um carregamento de drogas na residência, o corréu ALEX percebeu a presença da guarnição e correu para dentro do imóvel, momento em que os policiais decidiram ingressar na residência e flagraram os corréus VILSON e ARIZON descarregando tabletes de pasta-base de cocaína de uma Kombi semidesmontada, tendo o paciente e o corréu OSVALDO sido detidos no interior do domicílio. Realizada as buscas pessoais, veiculares e as demais diligências, a atividade policial logrou em apreender 107 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 95,245Kg. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver o paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

Recurso de habeas corpus. Prisão em flagrante. Guarda municipal. Apreensão de coisas. Legalidade. Delito permanente. – “A guarda municipal, a teor do dispositivo, § 8º do artigo 144 da CF, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do Município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta – também – a apreensão de coisas, objeto do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 – modalidade guardar substância entorpecente” (STJ – 6ª T. – RHC 7.916- Rel. Fernando Gonçalves – DJU 09.11.1998; Revista Jurídica 255/126; JSTJ e TRF-LEX 115/303).

“Não há ilegalidade na prisão, vez que realizada em flagrante delito, nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, por guardas municipais, ainda que não possuam a função de preservar a segurança pública (destinou-se-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais artigo 144, § 8º, da Constituição Federal). Ademais, como é cediço, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito (artigo 301, do Código de Processo Penal), constituindo notório contrassenso admitir que guardas municipais não possam proceder da mesma maneira legal.(TJSP – 14ª Câmara, Apelação nº 0017308-46.2010.8.26.0019, Relator Des. Marco de Lorenzi, j. 01.03.2012)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase préprocessual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada. (STJ, 5ª Turma, HC 129932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 15.12.2009).

Assim, não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dos policiais tem o mesmo valor que o de qualquer outra testemunha, ainda mais quando a mera alegação de “não comprovação da autorização de entrada” vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:
Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de

tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "os dados acidentais e os contornos acessórios do fato justificam o juízo condenatório, pois firmada a evidência de não corresponder a ação do réu, por qualquer argumento, ao uso de entorpecente. Assim, entendo que não deve ser aplicada a desclassificação ao caso em epígrafe, para que não seja violado aquilo que se conhece por razoável, na medida em que, na espécie, não se cogita do imponderável sobre a existência do fato e da autoria, mas, ao contrário, se denota, de forma efetiva, que a conduta do réu deve ser classificada como inclusa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006". Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela desclassificação da conduta do agravante para uso de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Admissibilidade - Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente - Condenação mantida O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a juízo para perseguir sistematicamente pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes. (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 159.299-3 - Botucatu - 18.08.94)

Assim, diversamente do sustentado, nenhum abuso ocorreu na diligência policial, desencadeada por patrulhamento de rotina. Tratando-se "de crime permanente, a ensejar sempre prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal" (JCAT 75/590).

No mais, conforme relatado, houve a devida autorização para a entrada na residência.

Desta forma, a grande quantidade de tóxico apreendida, bem como sua variedade, forma de acondicionamento e diversos apetrechos para sua preparação, evidencia a destinação de tráfico.

Por fim, não restou minimamente comprovada a alegação de quebra da cadeia, pela ausência de digitais na droga apreendida. No mais, não comprovou a parte o efetivo prejuízo, tendo em vista que o material apreendido (droga) foi devidamente periciado.

Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Não há dados a indicar quebra da cadeia de custódia. Na aferição da higidez da prova sob a óptica da cadeia de custódia, importa atentar, mais do que o cumprimento estrito das formalidades em si, para a finalidade do instituto. Neste passo e sempre tendo por parâmetro o princípio da instrumentalidade das formas - não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta, tal como tem assentado o Supremo Tribunal Federal (HC nº 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC nº 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC nº 123.890, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC nº 122.467, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE nº 868.516 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP nº 481 EIED, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros), impende aferir se, no caso concreto, as providências tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida sobre a identidade entre o material apreendido e o periciado, bem como no tocante à conservação do material apreendido para fins da perícia. Somente se deve declarar a invalidade se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em risco a credibilidade da prova. 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500337-16.2021.8.26.0571; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2021; Data de Registro: 29/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - TRÁFICO DE ENTORPECENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - PREJUÍZO À DEFESA - NÃO DEMONSTRADO - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS - INFUNDADA - RECURSO IMPROVIDO. Rejeita-se a

preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime de tráfico. Restando devidamente comprovada em juízo a materialidade e autoria delitiva, o decreto condenatório é medida imperiosa. (TJMS. Apelação Criminal n. 0000481-64.2021.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Paschoal Carmello Leandro, j: 26/10/2021, p: 29/10/2021)

Verifica-se que o art. 33 da Lei de Drogas apresenta diversos núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Assim, não é obrigatório a confirmação da efetiva comercialização das substâncias, já que o delito se consuma pelo fato do agente transportar e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que é indubitável na hipótese vertente.

É certo que a simples apreensão de grande quantidade que não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, a quantidade e diversidade expressiva, somada a forma de acondicionamento da substância entorpecente, além dos diversos apetrechos, é forte indício do comércio ilícito, que aliada às demais circunstâncias servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório.

A testemunha de defesa Marcos Antonio declarou que não presenciou a abordagem da polícia e não conhece o réu.

A testemunha de defesa Tania Mara disse que é vizinha da Vilma em Sumaré, mãe da esposa do réu. Declarou, ainda, que visualizou uma abordagem na casa da Vilma, perto das 14 horas, em 14/03/2022, não sabendo o motivo. Por fim, não presenciou a abordagem em Americana.

A testemunha Vilma Souza, genitora da companheira do réu disse que no dia 14/03/2022, perto das 14h, policiais adentraram sua casa em Sumaré, sem autorização, alegando uma denúncia e realizaram busca no quarto da filha.

Há que se analisar trata-se de declaração de ocorrência de abordagem em outra comarca, cerca de um mês após a prisão nestes autos, e sem qualquer prova material acerca da ocorrência. Desta forma, não há como se analisar qualquer ligação entre os fatos.

A testemunha de defesa Renith Paulino disse que presenciou a abordagem em 02 de fevereiro de 2022, perto das 9h da manhã. Disse que estava na rua, dirigindo-se a casa do réu para prestar serviços, e viu os policiais abordando o carro do réu, sendo que visualizou a revista, mas não viu nada retirado do veículo. Declarou, ainda, que com o controle os policiais abriram o portão e adentraram a casa. Por fim, ficou de longe, não indo até a casa.

E, a testemunha de defesa Rogério Bueno, declarando que possui um salão de cabelereiro, e não sabe onde o réu mora. Disse que tinha acabado de atender um cliente, momento em que houve uma abordagem e os policiais mandaram entrar. Narrou que não viu a vistoria no veículo.

A testemunha Rogério, nem ao mesmo sabe precisar onde o réu mora, isso porque, segundo a defesa, o estabelecimento é próximo a residência do réu. No mais, a alegação da defesa de impedimento de acompanhar a ação policial por transeuntes, resta refutada por sua própria testemunha, Renith, a qual alega ter visualizado parte do ocorrido.

Ainda, a testemunha Paula Regina, companheira do réu, declarou que escutou o portão

abrindo, achou que era o marido chegando e foi ver, quando foi abordada pelos policiais, com armas, sendo que adentraram a casa. Nega que tenha autorizado a entrada ou que tenha indicado onde a droga estava localizada. Disse que não acompanhou a ação dos policiais de busca na casa. Após os fatos, foi retirar os móveis da casa para mudar para a casa de sua mãe, e viu um carro na esquina. Na casa da sua mãe, em Sumaré, também teve abordagem da polícia, sendo que o policial disse que era ele quem havia preso o réu. Narrou que a balança e saquinhos eram para separar comidas para a cachorra que estava doente. Por fim, confirmou que existia a lavanderia e o armário nos fundos da casa. E confirmou que o réu tinha um veículo Ônix que foi acidentado, sendo que o réu tinha comprado outro carro para tirar as peças, tendo pago cerca de sete mil.

Em que pesem as declarações da testemunha de defesa, inclusive as ausente de compromisso, não podem ser consideradas para isentar o réu do delito.

Verifica-se que, na divergência entre os depoimentos das testemunhas, deve se dar preferência para o depoimento daquelas que não têm relação de parentesco com o réu, porquanto isentas. Assim já decidiram os nossos tribunais:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. (...). Materialidade e autoria que restaram indúvidas, especialmente pelas declarações da vítima confirmando a narrativa da denúncia, e o reconhecimento feito em sede policial, no dia seguinte ao roubo. Tese defensiva de negativa de autoria que não encontra respaldo na prova acusatória produzida, no que pese constituir-se esta, basicamente, do depoimento da vítima, sendo certo que as testemunhas de defesa são parentes do réu, e foram ouvidas como informantes, pelo que suas declarações devem ser apreciadas com reservas. (...). (TJ-RJ, APELAÇÃO 0012988-20.2006.8.19.0202 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Des(a). KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA - Julgamento: 31/07/2007)

Corrupção ativa – Oferecimento de dinheiro a policiais para que o réu não seja levado à delegacia - Apreensão de dinheiro e escritos que seriam relacionados com o tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Testemunhas de defesa que são parentes do acusado e cujas palavras devem ser recebidas com reservas – Prova segura - Condenação mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0390203-86.2010.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2012; Data de Registro: 02/05/2012)

PROVA - Testemunhos conflitantes - Prevalência daqueles oferecidos por pessoas estranhas aos partícipes da cena criminosa - Condenação mantida.126 - No conflito de versões oferecidas por pessoas desinteressadas quanto à sorte da demanda, estranhas aos envolvidos na infração e por pessoas sentimental e afetivamente ligadas a um dos personagens, claro que as declarações das primeiras se haverá de conferir credibilidade maior. RJDTACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 138 RELATOR:- CANGUÇU DE ALMEID

O acusado Wilquer negou a prática dos delitos. Disse que tinha financiado um veículo Ônix, e acabou se envolvendo em um acidente, com grandes danos. Declarou que procurando peças pela internet, acabou por localizar o outro carro, o qual seria de leilão, e não seria para rodar. Aceitou, pois precisava apenas das peças da lataria, para consertar seu veículo. A pessoa entregou o carro as 10h da noite, e pagou sete mil reais. Narrou que forneceu sua placa ao vendedor, e este já entregou com a placa trocada. No dia seguinte, ligou para o funileiro e quando estava saindo da casa foi abordado pela polícia. Foi informado pelos policiais que o carro era roubado, e queriam a “arma”. Disse que com o controle, os policiais foram até sua casa, e não acharam arma. Por fim, nada foi encontrado no veículo, e apenas na Delegacia soube acerca das drogas.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

Em que pesem as declarações da parte ré (entrada forçada e/ou não autorizada, e ação agressiva dos policiais), não restaram comprovadas, ressaltando-se que a alegação não comprovada é também indício que milita em desfavor do réu.

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Por fim, o delito tipificado no artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06, é subsidiário em relação ao crime descrito no artigo 33, caput. Assim, uma vez localizada substância entorpecente, e inexistentes fundadas razões para a dupla imputação da pena, configurado está o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que os fatos se deram no mesmo contexto. Nesse sentido os seguintes julgados: RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ANÁLISE. VIA INADEQUADA. DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. PERÍCIA DE VOZ. OBRIGATORIEDADE INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS POLICIAIS E JUDICIAIS. ARTS. 33, § 1º E 34 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CORRÉUS. IDENTIDADE OBJETIVA DE SITUAÇÕES. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. RATIFICAÇÃO DO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 579/STJ. INTERCEPTAÇÃO. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DA DEGRAVAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. FATOS DO PROCESSO. FALTA DE CORRELAÇÃO.

AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. 1.(...). 6. Segundo precedentes da Sexta Turma desta Corte, as condutas tipificadas nos arts. 33, § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006 têm natureza subsidiária em relação àquelas previstas no art. 33, caput, da mesma Lei (anteriormente previstas nos arts. 12 e 13 das